

1500657-38.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valinhos

Foro de Valinhos

1ª Vara

Rua Professor Ataliba Nogueira, 36, Valinhos-SP - cep 13270-660

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500657-38.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500657-38.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2052789/2021 - DEL.POL.PLANTÃO VALINHOS, 16405510 - DEL.POL.PLANTÃO VALINHOS, 195/21/938 - DEL.POL.PLANTÃO VALINHOS, 2052789 - DEL.POL.PLANTÃO VALINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO FRANCISCO COELHO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de DANILO FRANCISCO COELHO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, na qual lhe imputa a prática da infração penal descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Narra-se na denúncia que no dia 23 de fevereiro de 2021, às 19h20min, na Rua Vereador Reinaldo Rossi Filho, n. 64, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Valinhos, o acusado trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 6,4g de cocaína acondicionada em 28 microtúbulos plásticos do tipo eppendorf dotados de tampa própria, encerrando porção de material sólido particulado, 0,9g da mesma

substância, cocaína, acondicionadas em 13 microtúbulos plásticos tipo eppendorf dotados de tampa própria encerrando porção de material sólido petrificado e 9,7g de maconha embalada em 09 invólucros plásticos fechados por pressão.

Consta na denúncia, ainda, que “segundo restou apurado, os guardas municipais, diante de uma denúncia de que um indivíduo estava comercializando drogas próximo ao local dos fatos, se dirigiram ao local, avistando um indivíduo com as características descritas na denúncia, o denunciado Danilo. O denunciado, ao avistar a viatura da guarda, dispensou uma sacola e saiu correndo, sendo abordado posteriormente pelos guardas, oportunidade que foi realizada busca pessoal e foi encontrado um pino da substância cocaína, a quantia de R\$19,50 e um telefone celular da marca Motorola.”

Notificado (fls. 95), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 104/107). Recebida a denúncia (fls. 124/126), foi citado (fls. 146).

Audiência de instrução e julgamento ocorrida em 13 de setembro de 2022, momento em que ouvidas 02 testemunhas comuns à defesa e à acusação e, por fim, interrogado o réu.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa requereu a desclassificação do delito e, subsidiariamente, pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena especial do crime de tráfico de entorpecentes.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não existem preliminares a serem examinadas. Não se implementou prazo prescricional, tampouco nenhuma outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

Para o exame da comprovação da materialidade do fato descrito na denúncia, são relevantes, em especial, os seguintes elementos de informação e de prova: auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), laudos de exame pericial preliminar (fls. 31/33). Não há nos autos o laudo definitivo de constatação.

Ocorre que para a aferição da licitude e validade da prova da materialidade, imprescindível que sejam analisadas as circunstâncias em que se deram sua colheita. No ponto, passa-se a sumarizar os depoimentos colhidos.

A testemunha Gilmar Jose Barbosa, guarda municipal, ouvido em Juízo, aduziu que (a) receberam denúncia anônima da ocorrência de tráfico de droga por um indivíduo vestindo calça jeans e blusa azul, (b) o local é conhecido como ponto de venda de drogas e, por esta razão, ele e seu parceiro Bruno se dirigiram até lá, (c) ao se aproximarem, percebendo a viatura da guarda municipal, o acusado jogou uma sacola no chão e se sentou com outras pessoas que ali estavam, (d) ato contínuo, foi abordado pelos guardas municipais que, em busca pessoal, encontraram uma pequena quantia de droga (um pino de cocaína), dinheiro em um celular em sua posse, (e) o acusado já é conhecido nos meios policiais, pois já realizadas abordagens no mesmo local, (f) a guarnição da guarda municipal se deslocou até o suposto ponto de comercialização de drogas especificamente para averiguar a denúncia anônima recebida por telefone.

A testemunha Bruno Lima Medeiros, guarda municipal, ouvido em Juízo, aduziu que (a) receberam denúncia anônima da prática de tráfico no local em que realizada a prisão e se dirigiram até lá, (b) ao chegarem, se depararam com Danilo, que batia com as

características recebidas pela denúncia anônima, (c) visualizaram o momento em que Danilo dispensou uma sacola plástica no chão que, posteriormente, constatou-se tratar de substâncias entorpecentes, (d) o acusado já é conhecido nos meios policiais, inclusive já sendo abordado anteriormente no mesmo local dos fatos, (e) se deslocaram até o local especificamente para a apuração da denúncia de tráfico de drogas, prática esta comum da guarda municipal.

Por fim, interrogado o acusado Danilo Francisco Coelho de Oliveira, alegou que (a) estava com apenas um tubo de cocaína em sua posse, (b) mora na rua de cima em que realizada a abordagem, (c) os guardas municipais vasculharam uma mata nas proximidades, encontrando esta sacola contendo drogas, que não era sua, (d) já foi abordado diversas vezes pela guarda municipal.

Diante do acervo probatório acima sumarizado, a despeito das substanciosas razões apresentadas pelo Ministério Público em alegações finais pela condenação, constata-se que a absolvição por ausência de prova (CPP, art. 386, VII) se impõe, pois é consectário da ilicitude da empreitada investigativa e ostensiva empreendida pela guarda municipal, a qual implica a ilicitude da subsequente apreensão das drogas e respectiva perícia, por ser prova derivada, à luz do art. 5º, LVI, da CR/1988 e do art. 157, caput e § 1º, do CPP. Explico.

As guardas municipais exercem relevante serviço público de segurança, em sentido lato, nos termos do art. 144, parágrafo 8º, Constituição da República. Ocorre que suas funções se restringem à proteção do patrimônio municipal, incluídos os seus bens, serviços e instalações.

Em observância à função constitucional atribuída às guardas municipais, é certo que lhes é permitida a realização de patrulhamento preventivo, mas sempre vinculado – o patrulhamento –, à finalidade de tutelar o patrimônio público municipal.

Consequência lógica do raciocínio acima esposado, não incumbe à guarda municipal empreender operações de combate ao tráfico, realizar patrulhamento ostensivo em locais conhecidos pela comercialização de substâncias entorpecentes, ou mesmo apurar denúncias anônimas recebidas por linha telefônica.

Ainda nesta linha, mostra-se teratológica a situação ora apresentada: guardas municipais, ao receberem denúncia anônima de tráfico de drogas – em telefone disponibilizado pelo ente municipal especificamente para denúncias –, se deslocaram até o local, em verdadeira operação de natureza policial – em sentido estrito –, para averiguação dos fatos.

Registre-se, no ponto, que não há outras provas obtidas por fonte independente que possam, com base em nexo de causalidade diverso, dar amparo à comprovação do fato-crime, à luz do art. 157, § 1º, do CPP, e tampouco há no caso demonstração de hipótese de descoberta inevitável pelos trâmites típicos e de praxe da investigação, à luz do art. 157, § 2º, do CPP.

O laudo pericial sobre as drogas apreendidas é o único meio de prova admitido na legislação processual penal para a comprovação do tráfico de drogas (CPP, art. 158), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AgRg no HC 492.906/MS, Quinta Turma, DJe 12/09/2019 e HC 497.242/CE, Sexta Turma, DJe 12/08/2019).

Diante da dinâmica fática supra sintetizada, bem evidenciada pela instrução processual, não há como afastar a ilicitude do meio de obtenção de prova empregado, pois a guarda municipal, ao realizar operação de natureza policial para averiguação do crime de tráfico de drogas, agiu em flagrante desvio de finalidade às suas funções constitucionais. Trata-se de entendimento adotado pelo C. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras "polícias municipais", mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte - apesar das investidas em contrário - por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal.
2. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil - em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência - estão sujeitas a rígido controle correccional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais - apesar da sua relevância - não estão sujeitas a nenhum controle correccional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal.
3. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar - em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais - o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros.
4. A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para "Polícia Municipal". Ademais, inúmeros municípios pelo país afora - alguns até mesmo de porte bastante diminuto - estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas.
5. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito.
6. Ao dispor no art. 301 do CPP que "qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.
7. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui

generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações.

8. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais - e por isso interpretadas restritivamente - nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária.

10. Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito.

11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese.

12. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Tendo em vista que toda a prova da materialidade do delito foi obtida a partir de atividade com desvio das finalidades atribuídas aos agentes públicos municipais, deve ser reconhecida a sua ilicitude por derivação.

Não se nega que o tráfico de drogas é crime grave, que traz consigo consequências sociais diversas e indesejáveis. Ocorre que o Estado-Juiz, ao se deparar com afrontas à ordem constitucional praticadas pelo próprio Estado, sob alegação de combate ao crime, não deve ratificar tais condutas.

No ponto, é elucidativa a célebre e já quase centenária passagem do Justice Louis D. Brandeis, da Suprema Corte americana: “Em um governo de leis, a existência do Estado estará sob risco se este deixar de observar a lei escrupulosamente. O Estado [...], bem ou mal, orienta todo o povo pelo seu exemplo. O crime é contagioso. Se o Estado se torna um infrator da lei, ele convida à anarquia. Declarar que, na administração da justiça criminal, os fins justificam os meios – declarar que o Estado pode cometer crimes com o objetivo de assegurar a punição de um determinado criminoso – atrairia um terrível castigo” (Olmstead v. United States 277 US 485, 1928, tradução livre).

Portanto, embora as provas apontem sim a materialidade e a autoria da infração penal, tais provas são ilícitas por derivação e, conseqüentemente, inadmissíveis na forma do art. 5º, LVI, da CR/88 e do art. 157, caput e § 1º do CPP. Logo, impõe-se a absolvição por ausência de provas lícitas aptas à comprovação da materialidade e autoria da infração penal descrita na denúncia.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de ABSOLVER DANILO FRANCISCO COELHO DE OLIVEIRA da imputação contra si formulada neste feito, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Promova-se a destruição das amostras de droga eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Promova-se a restituição dos valores e outros bens lícitos eventualmente apreendidos ao acusado, na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Sem custas (CPP, art. 804).

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º).

Intimem-se o Ministério Público, a defesa técnica e o acusado.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Valinhos, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA